

1506816-84.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... recebia 50 reais ao dia para fazer o tráfico, não mencionaram se faziam o tráfico juntos; o local é dentro de comunidade, embora houvesse pessoas pelo local, costuma juntar gente em volta hostilizando a polícia, assim não conseguem levar testemunhas.

O policial militar Rafael descreveu em Juízo que estavam fazendo uma operação pela área em razão de um roubo ocorrido na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506816-84.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506816-84.2021.8.26.0228 - 2021/000407

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

EDUARDO ALENCAR DE SOUSA e JOSÉ NARCIO DE NEGREIROS NETO

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

EDUARDO ALENCAR DE SOUSA e JOSÉ NARCIO DE NEGREIROS NETO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em combinação com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque teriam, no dia 18 de março de 2021, por volta de 9h40, na Rua Juliana Vigna nº 10, Raposo Tavares, nesta cidade e Comarca, durante estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, previamente ajustados e em identidade de desígnios, trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, 310 porções com 170,3 gramas de cocaína, 100 porções com 20,5 gramas de crack, e 140 porções com 292,4 gramas de maconha, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 81/85), concedida liberdade provisória no curso do feito (fls. 112/113).

Os acusados foram regularmente citados e notificados (fls. 151), e apresentaram defesa preliminar, Eduardo por meio de defensor constituído (fls. 146/150) e José

Narcio através da Defensoria Pública (fls. 154/155), recebida a denúncia (fls. 159) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de penas no mínimo, atenuadas pela menoridade relativa de Eduardo e pela confissão de ambos, com máxima redução, em regime brando tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, caracterizada por comparsaria, correta a classificação dada à conduta.

O réu Eduardo, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 9), ouvido em Juízo, admitiu a prática do tráfico, dizendo que estava no local como "olheiro", mas que não estava vendendo e não tinha drogas consigo; estava com 15 reais em dinheiro e um celular motorola com o qual estava falando com José, que era quem estava vendendo; viu a chegada da viatura policial, correu para o meio da favela, onde havia mais outros policiais; correu para uma viela sem saída, onde acabou sendo detido; admitiu aos policiais que estava de "campana"; José foi detido em separado, não viu quando ele foi abordado, pelo que soube foi apreendida droga com José; ia ao local dia sim, dia não, das 7 às 12h, havia uma semana, recebendo R\$ 30,00 por dia, sempre junto com José, que era seu conhecido de infância; trabalhava numa lanchonete, mas foi demitido por causa da pandemia, ficou em dificuldades financeiras; está trabalhando como ajudante geral em uma empresa de engenharia, sem registro na CTPS, e está terminando o ensino médio; negou ser usuário de drogas; negou antecedentes.

O réu José Narcio, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 10), ouvido em Juízo, admitiu a prática do tráfico, dizendo que estava vendendo drogas, tendo consigo cerca de 30 porções de cocaína; tinha consigo também um pouco de dinheiro e um celular, que estava usando para ficar em contato com Eduardo, que estava de olheiro; não estavam juntos, Eduardo estava na parte de baixo olhando, enquanto estava na parte de cima vendendo; quando a polícia chegou, tentou sair do local, mas foi detido; foi apreendida a pochete onde levava a droga; não tinha consigo nenhuma porção de maconha, não sabe onde foi apreendida; não presenciou a abordagem de Eduardo; era seu primeiro dia no local, tinha perdido o emprego em razão da pandemia e estava com dificuldades financeiras; conhecia Eduardo desde a infância; atualmente mora com sua companheira e está trabalhando como entregador para o iFood, de bicicleta; negou ser usuário de drogas; negou antecedentes.

A confissão de coautoria prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa significativamente do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão das drogas, celulares e dinheiro foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Guilherme relatou em Juízo que estavam participando de uma operação em vista de roubos que vinham ocorrendo na região, especialmente um na véspera no Carrefour; quando entraram pelo local, onde há conhecido ponto de tráfico, viram várias pessoas correndo, inclusive os dois réus, que entraram em uma viela sem saída; desembarcaram e foram atrás dos réus; o réu Eduardo dispensou uma pochete, que foi apreendida; no final da viela, José foi detido quando tentava subir pelo muro, ao passo que Eduardo subiu pelo muro para cima do telhado de uma casa e dali caiu; diretamente com Eduardo nada foi apreendido, mas na bolsa que ele

dispensou havia celular e porções de maconha, cocaína e crack, além de cerca de 15 reais em dinheiro; na busca pessoal, nos bolsos e por dentro da blusa de José, encontraram várias porções de cocaína e também cerca de 100 reais em dinheiro; viu o gesto e tem certeza de que foi Eduardo quem dispensou a bolsa; os réus não eram residentes no bairro, ambos disseram que cada um recebia 50 reais ao dia para fazer o tráfico, não mencionaram se faziam o tráfico juntos; o local é dentro de comunidade, embora houvesse pessoas pelo local, costuma juntar gente em volta hostilizando a polícia, assim não conseguem levar testemunhas.

O policial militar Rafael descreveu em Juízo que estavam fazendo uma operação pela área em razão de um roubo ocorrido na véspera no Carregor; quando entraram na viela, os dois réus correram, as pessoas que estavam pela rua foram entrando nas casas; um dos réus jogou uma sacola e subiu num telhado, de onde caiu quando as telhas quebraram; conseguiu segurar o outro réu, com quem apreendeu porções de maconha e cocaína, dinheiro e um celular; na bolsa que o outro dispensou encontraram também porções de maconha e cocaína, dinheiro e celular; os réus admitiram que estavam traficando, não se recordava se era moradores do local; não se recordava se havia morador presente na casa em cujo telhado o réu subiu; não houve testemunha que pudessem conduzir.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Bem assentado, assim, que os réus foram mesmo surpreendidos em plena prática delituosa, quando colaboravam mutuamente para o tráfico, tendo consigo não apenas as porções de cocaína que José admitiu que levava consigo, mas também as porções de crack e de maconha que foram efetivamente apreendidas nas circunstâncias descritas pelas testemunhas.

As testemunhas explicaram, ademais, que não havia, além dos dois réus, outras pessoas envolvidas na ocorrência, não sendo esperado que fossem à caça de transeuntes ou moradores para compeli-los a acompanhar a ação policial ou para olhar os objetos que foram apreendidos.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 22/23, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 45/48 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 174/176, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (553 porções), a variedade (cocaína em papérols e eppendorfs, maconha e crack), o modo de disposição das drogas e as circunstâncias em que apreendidas, quando postados os réus em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido (R\$ 199,00).

A condenação dos acusados é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231). Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da

pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

A causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º incide em grau máximo frente à primariedade dos acusados, demonstrada pelas FAs de fls. 55/57 e 58/60, e à ausência de notícia de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, ademais demonstrada pelos documentos de fls. 182 e ss. que os réus vêm estudando e trabalhando, capacitados a vida regrada e ordeira. Vão as penas, pois, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

A suspensão condicional da pena, contudo, passível de revogação com obrigação de integral cumprimento da pena corporal é admissível, acenando com mais relevante consequência, melhor atendendo ao reclamo de proporcionalidade da pena.

Determino, pois, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, ao longo do qual obrigados os condenados a comparecer mensalmente perante o Juízo de Execução para informar e justificar suas atividades, ficando proibidos de mudar de endereço e de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, os réus estão obrigados a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados,

estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus EDUARDO ALENCAR DE SOUSA, qualificado a fls. 9, e JOSÉ NARCIO DE NEGREIROS NETO, qualificado a fls. 10, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em combinação com o artigo 29 do Código penal, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigados os réus a comparecimento mensal perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibidos de mudança de endereço e de ausência da Comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano da suspensão, deverão prestar serviços à comunidade ou a entidades público, conforme dispuser o Juízo de execução.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo os réus respondido soltos, sem percalços, ao processo, faculto-lhes o recurso em liberdade.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intinem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamentos; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 22/23 e depositado a fls. 51 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) empregados os aparelhos celulares apreendidos a fls. 22/23 para a prática do tráfico, decreto seu perdimento; oficie-se para leilão com subsequente recolhimento do produto ao Funad; infrutífero o leilão, fica autorizada a destruição dos bens; e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida aos réus a gratuidade processual.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intinem-se. Comunique-se.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA